

1501578-82.2020.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EXASPERADA PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE NA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

2ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501578-82.2020.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501578-82.2020.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2239832/2020 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 13834242 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 1069/20/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2239832 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE BIBIANO DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA

VISTOS.

FELIPE BIBIANO DA SILVA e WILLIAN BIBIANO DA SILVA, já qualificados, foram denunciados como incurso no art.33 "caput" da lei 11.343/06 e art.329 "caput" do Código Penal.

Apresentada a defesa preliminar, a denúncia foi recebida. Foram juntadas aos autos folhas de antecedentes (fls.286 ss.) e laudo de exame químico toxicológico (fls.280

ss.).

Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas comuns e os réus foram interrogados e as partes se manifestaram em alegações finais (fls.299).

É o relatório.

DECIDO.

Afasto as preliminares arguidas pela douta Defesa. De fato, os réus foram presos em decorrência de mandado de prisão temporária expedido em desfavor do réu Felipe e por posse/trafego de entorpecentes, crime permanente.

Em assim sendo, não ocorreu qualquer ilegalidade no momento da prisão. Os policiais tinham em mãos mandado de prisão temporária em desfavor do réu Felipe, bem como um mandado de busca e apreensão para o seu endereço residencial; como ele não foi localizado, foram cumprir os mandados no endereço no qual o réu Felipe se encontrava. O mandado de prisão pode ser cumprido em qualquer endereço. Ao chegar ao endereço onde ele foi se encontrava, a entrada lhes foi livremente franqueada pela mãe dos acusados.

Assim, ao procederam ao cumprimento do mandado de prisão temporária do réu Felipe, ingressaram os policiais na residência onde ele estava e lá ele e o réu Willian ofereceram resistência a prisão. Em razão da resistência e em decorrência do cumprimento do mandado de prisão, procederam a uma revista no local e encontraram as drogas escondidas na lavanderia. Portanto, na realidade a revista no local não decorreu do mandado de busca e apreensão (o qual foi expedido para ser cumprido em outro endereço), mas do cumprimento do mandado de prisão em desfavor do réu Felipe, do livre acesso a residência e da resistência oferecida pelos réus.

Quanto ao mérito, por sua vez, a ação penal procede.

Os policiais civis ouvidos em juízo disseram que foram até o local com o intuito de cumprir mandado de busca e apreensão e prisão temporária em desfavor do réu Felipe; informaram que se tratava da residência da mãe dos acusados e ela abriu a porta. Os réus tentaram fugir e ofereceram resistência à prisão e entraram em luta corporal com os policiais. O policial Rafael narrou que ficou ferido durante a ação.

Os policiais ainda disseram que em revista pela residência, lograram encontrar as drogas embaixo de uma máquina de lavar, na área de lavanderia. Os réus não assumiram a posse ou propriedade das drogas. Os policiais disseram que o réu Felipe já era conhecido nos meios policiais pela prática de homicídios e tráfico de entorpecentes.

O réu Felipe, ao ser interrogado, negou os fatos; disse que brigou com a mulher e foi passar a noite na casa da mãe e os policiais invadiram o local e o agrediram; disse que não havia drogas na casa. Tem outras passagens criminais.

Já o réu Willian, ao ser interrogado, disse que não ofereceu resistência aos policiais e que estes é que o agrediram e que foram encontradas drogas na casa e que o réu Felipe "assumiu" as drogas; disse que Felipe assim o fez, eis que os policiais disseram que, caso ele não assumisse, a mãe deles seria presa. Tem passagem por tráfico de drogas e está cumprindo a pena. Informou que morava com a mãe e que Felipe foi apenas passar a noite ali.

Portanto, não restam dúvidas quanto a autoria delitiva.

O simples fato de a testemunha de acusação ser policial, por sua vez, não invalida, por si só, seu depoimento (...). Neste sentido farta Jurisprudência (RJTJSP 151/67;

115/253; RT 426/439; 411/266).

O fato dos réus serem eventualmente usuários de drogas é irrelevante no caso. De fato, há de se ponderar que a condição de dependente não exclui, por si só, a condição de traficante, sendo possível a coexistência das características de traficante e viciado. Neste sentido farta jurisprudência (RT 736/712; RJTJSP 101/498; 84/382; RJTJSR 179/152).

Os réus, por sua vez, não produziram nenhuma prova em seu favor.

A materialidade vem evidenciada pelo laudo químico toxicológico de fls.280 ss. e pelos demais autos de apreensão juntados aos autos.

Há de ser reconhecido, por outro lado, o crime de resistência, eis que os policiais narraram que ambos os réus reagiram a prisão de forma violenta e um dos policiais chegou a ficar ferido durante a prisão.

Os réus possuem péssimos antecedentes e ostentam passagens por crimes de tráfico de drogas e homicídio e William inclusive possui condenação anterior demonstrando, assim, serem pessoas seriamente comprometidas com a criminalidade, daquelas que devem ser segregadas de forma definitiva da sociedade. Em assim sendo e considerando o disposto no art.59 do Código Penal, fixo a pena base para o crime de tráfico de entorpecentes em 06 anos de reclusão, os quais deverão ser cumpridos em regime fechado e para a resistência em 03 meses de detenção em regime semiaberto. Considerando a reincidência do réu William, aumento as penas em 1/6, num total de 07 anos de reclusão para o crime de tráfico de drogas, a serem cumpridos em regime fechado e 03 meses e 15 dias para o crime de resistência, a serem cumpridos em regime semiaberto.

Deixo de diminuir as penas nos termos do que dispõe o art.33§4º da lei 11.343/06, visto que os réus não preenchem os requisitos necessários. É evidente que fazem parte de organização criminosa. A própria atividade da mercancia de entorpecentes não pode ser dissociada da atividade de uma organização criminosa. Ora, há sempre a grande organização criminosa que adquire e distribui a droga, que a entrega aos fornecedores e estes aos vendedores.

Os réus não poderiam agir sozinhos, dissociados de uma rede muito bem organizada e articulada.

Aliás, neste sentido se posiciona a Jurisprudência:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE EXASPERADA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CORRETO AFASTAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - De forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, as instâncias ordinárias consideraram a quantidade e a natureza da droga apreendida com o paciente - 16 kg de maconha -, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a ser sanada pela via do writ. III - A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organizações criminosas. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 30/5/2017). IV - Na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na quantidade de drogas apreendidas, vale dizer, 16

quilos de maconha, elemento apto a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois evidenciam que o paciente se dedica às atividades criminosas. Precedentes. V - Ademais, rever esse entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 495838 MS 2019/0059322-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019).

HABEAS CORPUS Nº 495.838 - MS (2019/0059322-5) RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ADVOGADOS :
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SANDRA REGINA SANTOS DE
VASCONCELOS - MS004313 IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL PACIENTE : ANTONIO MARCIO AVELINO (PRESO) EMENTA PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE
EXASPERADA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADE CRIMINOSA. CORRETO AFASTAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A
Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do
col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de
habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a
concessão da ordem de ofício. II - De forma motivada e de acordo com o caso
concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código
Penal, as instâncias ordinárias consideraram a quantidade e a natureza da droga
apreendida com o paciente - 16 kg de maconha -, para exasperar a reprimenda-base,
inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a ser sanada pela via do writ. III - A
teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime
de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços),
quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se
dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organizações criminosas. Na falta
de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores
decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais
circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até
mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do
agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Sexta Turma, Rel.
Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 30/5/2017). IV - Na espécie, ao contrário do
que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do
tráfico privilegiado, lastreada na quantidade de drogas apreendidas, vale dizer, 16
quilos de maconha, elemento Documento: 1840691 - Inteiro Teor do Acórdão - Site
certificado - DJe: 25/06/2019 Página 1 de 4 Superior Tribunal de Justiça apto a
justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06,
pois evidenciam que o paciente se dedica às atividades criminosas. Precedentes. V -
Ademais, rever esse entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição
demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória,
procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.
Habeas corpus não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que
são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer do pedido. Os Srs. Ministros
Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro
Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik. Brasília
(DF), 18 de junho de 2019(Data do Julgamento) Ministro Felix Fischer Relator

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENA-BASE DO CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS EXASPERADA PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE
ENTORPECENTES. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE NA DEDICAÇÃO DO

PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICADO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 depende do convencimento do Magistrado, de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa. 5. Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade das drogas apreendidas e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do paciente a atividades criminosas, que restou evidenciada pelas circunstâncias da apreensão, com destaque para a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos. (...) (STJ. HC 427339 RJ 2017/0313649-4. T5 - QUINTA TURMA. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Julg. 27/08/2018. DJe 08/03/2018) Grifos não contidos no original.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DROGA DE ALTOR PODER DESTRUTIVO E QUANTIDADE RAZOÁVEL. BENESSE NÃO APLICADA. (...) 3. A natureza da substância entorpecente de alto poder destrutivo e a relevante quantidade de psicotrópicos apreendida obstam a incidência da minorante do tráfico privilegiado. (TJ-AM. 00004617220178045600 AM 0000461-72.2017.8.04.5600. Primeira Câmara Criminal. Rel. Carla Maria Santos dos Reis. Julg. 14/05/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA PATAMAR PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (COCAÍNA) - 2. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - INVIÁVEL RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PRECEDENTES DO STF E STJ - 3. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, PARA UM DIVERSO DO FECHADO - NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA IMPEDEM A MODIFICAÇÃO - ENUNCIADO Nº. 47 DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. 2. Sendo constatada considerável quantidade de droga apreendida, e tendo o magistrado sentenciante se utilizado desses vetores para não aplicar o tráfico privilegiado, o réu não faz jus ao redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11343/06. Precedentes do STF e STJ. (TJ-MT. Ap 18857/2018. Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva. Terceira Câmara Criminal. Julg. em 12/09/2018. Pub. no DJE 21/09/2018) Grifos não contidos no original.

"A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no AREsp n. 1035945/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018). Assim, mantido o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas" AgRg no AREsp 1293358/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 10/5/2019)." (HC 511.370/RJ, j. 04/06/2019)

Por fim, trata-se de nítida hipótese de concurso material de crimes, de sorte que as penas dos réus serão somadas, nos termos do art.69 do Código Penal. Os réus podem ser considerados pessoas pobres na acepção jurídica do termo, assim, fixo-lhes a pena pecuniária referente ao crime de tráfico de drogas em 500 dias-multa, no mínimo legal.

Os réus praticaram crimes graves, daqueles que causam intranquilidade e comoção social, além de serem criminosos contumazes e indivíduos potencialmente perigosos (no sentido lato), motivos pelos quais persistem os requisitos do art.312 do Código de Processo Penal, não fazendo eles jus à liberdade provisória.

DIANTE DO EXPOSTO, condeno FELIPE BIBIANO DA SILVA, já qualificado, a 06 anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal e 03 meses de detenção em regime semiaberto por incurso no art.33 "caput" c.c.329

“caput” do Código Penal na forma do art.69 do Código Penal.

Condeneo WILLIAN BIBIANO DA SILVA, já qualificado, a 07 anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal e 03 meses e 15 dias de detenção em regime semiaberto por incurso no art.33 “caput” c.c.329 “caput” do Código Penal c.C.Art.61, inciso I, na forma do art.69 do Código Penal. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram. Após o trânsito em julgado, lancem os seus nomes no Rol dos Culpados. Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Embu das Artes, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA